



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
X SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaele Miele ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2157 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 20/1/2021, svoltasi nelle modalità previste dall'art. 83, co 7, lett. h) del D.L. 18/2020, con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e vertente

TRA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*)

elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Poma n. 4, presso lo studio dell'avv. Paolo Gelli che lo rappresenta e difende per procura in atti

ATTORE

CONTRO

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante p.t.

elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare n. 71, presso lo studio dell'avv. Gianluca Indaco che la rappresenta e difende per procura in atti

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti concludevano come da note scritte in atti da intendersi integralmente riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell’art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell’art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall’art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).

Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e i verbali di causa.

Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti e, sia pure brevemente, le rispettive deduzioni ed eccezioni.

Parte_1 ha agito in giudizio nei confronti della *Controparte_1* per sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“Accertato l’inadempimento di Controparte_1 al contratto preliminare stipulato in data 5/2/2016 ed accertato che l’odierno attore ha dichiarato espressamente di recedere dal contratto, dichiarare la legittimità del recesso del sig. Parte_1 dal contratto preliminare di acquisto stipulato con Controparte_1 con conseguente condanna della stessa parte promittente alienante alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria ricevuta all’atto della sottoscrizione del contratto stesso, per un importo pari ad €. 30.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In via subordinata accertata l’intervenuta risoluzione del contratto preliminare per grave inadempimento di Controparte_1 condannarla alla restituzione della caparra confirmatoria versata dall’odierno attore, oltre al rimborso della somma di €. 5.000,00 corrisposta per spese di agenzia e al risarcimento di ogni ulteriore danno nella misura che sarà documentata nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In via ancora subordinata, dichiarare che Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore non ha adempiuto all’obbligazione di trasferire al sig. [...] Parte_1 i beni immobili promessi in vendita e conseguentemente emettere a carico della Controparte_1 ed in favore del sig. Parte_1 sentenza che ai sensi dell’art. 2932 cc produca gli effetti del contratto definitivo non concluso e trasferisca al sig. Parte_1 la proprietà dei beni, previa regolarizzazione della pratica urbanistica in modo che vi sia perfetta corrispondenza tra lo stato di fatto e lo stato di diritto, dichiarandosi il sig. Parte_1 pronto a versare la residua quota del prezzo come previsto nel contratto preliminare. (...) In ogni caso con condanna della convenuta alle spese e compensi di lite”*.

A tal fine, l'attore ha sostanzialmente esposto che: 1) in data 5/02/2016 aveva sottoscritto con la *Controparte_1* un contratto preliminare di acquisto avente a oggetto le porzioni immobiliari situate nell'ambito del Comprensorio "Torrino-Mezzocamino" nel sub Comparto Z 22 sagoma H, con accesso da Via Gianluigi Bonelli n. 341 e accesso carrabile da Via Guglielmo Letteri n. 23 (meglio indicate in atti); 2) con il suddetto contratto la promittente alienante aveva garantito sia il trasferimento degli immobili liberi da vincoli, pesi ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli sia che gli stessi non erano stati oggetto di ulteriori opere subordinate al rilascio di provvedimenti autorizzativi o concessori, dando atto che gli stessi erano conformi alle norme urbanistiche in vigore e si era impegnata a realizzare a sua cura e spese il previsto aumento di cubatura avvalendosi dello strumento urbanistico del Piano Casa già approvato e ad attuare il cambio di destinazione d'uso parziale, il tutto entro e non oltre la data del 15/5/2016; 3) il prezzo di vendita era stato determinato in € 180.000,00, di cui € 15.000,00 a titolo di caparra confirmatoria versata con bonifico bancario alla data sottoscrizione del preliminare ed € 165.000,00 da pagare al momento del rogito con assegno circolare; 4) per la stipula dell'atto pubblico di compravendita era stata convenuta la data del 30/06/2016, da intendersi quale termine essenziale e improrogabile, e che la promittente alienante si era impegnata a fornire la documentazione necessaria a tal fine in tempo utile; 5) in sintesi la tempistica per la compravendita era stata così programmata: -) 5/2/2016, quale data della stipula del preliminare; -) 15/5/2016, quale data di realizzazione dell'aumento di cubatura con il Piano Casa e di attuazione del cambio di destinazione d'uso parziale; -) fine maggio 2016, quale periodo di consegna della documentazione al notaio indicato da parte acquirente; -) 30/6/2016, quale data del rogito; 6) tuttavia la *Controparte_1* non aveva adempiuto gli impegni assunti, avendo provveduto a eseguire gli incombenenti su di essa gravanti e, in particolare, a presentare le richieste di autorizzazione necessarie all'esecuzione dei lavori che aveva realizzato solo successivamente alla scadenza del termine del 30/6/2016 previsto per la stipula dell'atto; 7) le attestazioni rese nel contratto dalla promittente alienante in ordine alla mancata esecuzione di opere ulteriori soggette a provvedimenti autorizzativi o concessori nonché alla conformità dell'immobile promesso in vendita alle prescrizioni urbanistiche vigenti, non erano pertanto veritiere; 8) la *Controparte_1* aveva perciò posto in essere una condotta gravemente inadempiente, impedendo la stipula dell'atto pubblico di compravendita entro il termine essenziale previsto nel preliminare; 9) inoltre le modifiche apportate dalla stessa allo stato dei luoghi avevano determinato una trasformazione giuridico-urbanistica strutturale dell'immobile oggetto del preliminare, con conseguente impossibilità di addivenire al rogito; 10) tali gravi inadempimenti erano tali da legittimare il proprio recesso dal contratto con relativo diritto a ottenere, ai sensi dell'art. 1385 c.c., la restituzione del doppio della caparra versata all'atto della sottoscrizione del preliminare; 11) inoltre la scadenza del termine

essenziale fissato nel preliminare aveva determinato, ex art. 1457 c.c., la risoluzione di diritto del preliminare, con conseguente obbligo della promittente alienante di restituire la caparra versata; 12) peraltro la convenuta aveva nuovamente posto in vendita gli immobili di cui al preliminare, senza però restituire il danaro ricevuto a titolo di caparra e senza rispettare l'impegno di alienare il bene; 13) con raccomandata del 28/11/2017, in riscontro alla comunicazione del 16/11/2017 con cui la CP_1 [...] lo aveva diffidato ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., aveva intimato alla società il pagamento dell'importo di €. 30.000,00 pari al doppio della caparra versata, e aveva chiesto il rimborso della somma di €. 5.000,00 corrisposta per spese di agenzia e il risarcimento di ogni ulteriore danno.

Si è costituita in giudizio la Controparte_1 contestando la ricostruzione attorea e deducendo che: 1) con il contratto preliminare stipulato tra le parti – avente a oggetto un locale soffitta, il relativo lastrico solare e un posto auto scoperto – si era impegnata a realizzare l'aumento di cubatura e a ottenere il cambio di destinazione d'uso approfittando della normativa del “piano casa”; 2) alla luce di tali pattuizioni, le “difformità” tra quanto attualmente esistente e quanto indicato nel preliminare erano inevitabili; 3) inoltre il Parte_1 era perfettamente a conoscenza delle trasformazioni che si apprestava ad apportare; 4) come confermato dalla relazione tecnica di parte depositata agli atti, tutte le successive integrazioni e varianti lamentate nell'atto di citazione erano state effettuate per ridistribuire diversamente la capacità edificatoria eccedente su altre unità immobiliari dello stesso fabbricato; 5) il termine del 30/06/2016, indicato nel preliminare, non era da intendersi come essenziale, in quanto la sua scadenza non aveva comportato il venir meno per nessuna delle parti dell'utilità del contratto; 6) tanto valeva altresì per il termine del 15/05/2016 fissato per il compimento delle attività edificatorie e amministrative, volte a ottenere l'aumento di cubatura e il cambio di destinazione d'uso; 7) aveva pertanto integralmente adempiuto quanto previsto nel preliminare; 8) alcun recesso era mai stato esercitato dal Parte_1 il quale aveva per la prima volta formulato le sue contestazioni solo dopo essere stato diffidato ad adempiere alla sottoscrizione del definitivo in data 16/11/2017; 9) anzi, l'attore era così poco intenzionato a recedere che, per tutto il 2017, le aveva richiesto di pazientare, perché stava avendo difficoltà a ottenere il mutuo; 10) infatti nel febbraio del 2017 aveva compiutamente adempiuto gli impegni assunti, sicché nulla avrebbe ostato alla stipulazione dell'atto notarile, cui il Parte_1 era stato più volte invitato a procedere; 11) anche successivamente al febbraio 2017, l'attore le aveva inviato innumerevoli messaggi nei quali ribadiva la sua volontà di procedere alla compravendita definitiva, in tal modo non solo rinunciando al termine ma altresì rinnovando per iscritto il suo impegno a concluderla; 12) infine la domanda ex art. 2932 c.c., formulata in via subordinata, era stata proposta con temerarietà e in via strumentale, al solo scopo di trascrivere l'atto di citazione, con conseguente applicabilità dell'art. 96, I e II comma, c.p.c..

La società convenuta ha quindi richiesto di rigettare tutte le domande attrici nonché di condannare *Parte_1* al risarcimento dei danni, da liquidarsi equitativamente, ex art. 96 c.p.c.

Nel corso del procedimento è stato emesso ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a carico di *Org_1* [...] Filiale di Cagliari, avente a oggetto la relazione peritale redatta sull'immobile oggetto di causa, finalizzata all'ottenimento del mutuo richiesto dal *Parte_1* sono state disattese le richieste di prova orale avanzate dalle parti, alla stregua dell'ordinanza del 18/12/2018 che qui si intende riportata e confermata ed è stata espletata una c.t.u.; all'esito la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

Parte_1 ha agito in giudizio nei confronti della *Controparte_1* deducendo il grave inadempimento di quest'ultima per aver determinato la trasformazione giuridico-urbanistica dell'immobile oggetto del contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti, per aver impedito la sottoscrizione del contratto definitivo entro il termine essenziale indicato nel preliminare, nonché per essersi sottratta all'impegno assunto nei propri confronti, avendo proposto a terzi l'alienazione dello stesso bene che gli era stato promesso in vendita.

In relazione a quanto precede, l'attore ha quindi richiesto all'intestato Tribunale, ritenuto il grave inadempimento della convenuta, di accertare la propria formale dichiarazione di recesso dal contratto e dichiararne la legittimità con conseguente condanna della stessa alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria; in subordine, di accertare l'intervenuta risoluzione del contratto preliminare, con condanna della convenuta alla restituzione della caparra, al rimborso della somma di € 5.000,00 corrisposta per spese di agenzia e al risarcimento di ogni ulteriore danno documentato nel corso del giudizio; in via ulteriormente subordinata, di dichiarare che *Controparte_1* non avesse adempiuto l'obbligazione di trasferirgli i beni immobili promessi in vendita e conseguentemente emettere sentenza che ai sensi dell'art. 2932 c.c. producesse gli effetti del contratto definitivo non concluso.

Tanto premesso, deve rilevarsi come il recesso contemplato dall'art. 1385, II comma, c.c., costituisca uno speciale strumento di risoluzione di diritto del contratto, collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria, analogo a quelli previsti dagli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., che in quanto tale condivide con la risoluzione giudiziale sia i presupposti, richiedendo un inadempimento di non scarsa importanza, sia le conseguenze, comportando la caducazione retroattiva degli effetti del contratto (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. II, 31/01/2019, n. 2969). In tal senso, è stato chiarito che *“La disciplina dettata dal secondo comma dell' art. 1385 c.c., in tema di recesso per inadempimento nell'ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per*

inadempimento, consentendo il recesso di una parte solo quando l'inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 08/08/2019, n. 21209).

Ne consegue che, con riferimento alla ripartizione dell'onere probatorio, il creditore che agisce in giudizio, per la risoluzione (e dunque anche per il recesso), deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (v. per tutte Cass. Civ. Sez. Un. 30 ottobre 2001, n. 13533).

Ciò posto, nel caso di specie **Parte_1** a sostegno delle proprie pretese, ha prodotto: 1) il contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti in data 5/02/2016, da cui risulta l'avvenuto versamento, in favore della società promittente venditrice, della somma di € 15.000,00 a titolo di caparra confirmatoria (cfr. doc. n. 1 allegato all'atto di citazione); 2) la documentazione concernente gli interventi urbanistici e catastali posti in essere dalla **Controparte_1** successivamente al termine del 30/06/2016, fissato per la sottoscrizione del contratto definitivo (cfr. doc. nn. 10 – 20 allegati all'atto di citazione); 3) la contestazione dell'inadempimento mossa nei confronti della società convenuta in data 28/11/2017 – e ricevuta il 30/11/2017 – in risposta alla diffida ad adempiere da quest'ultima inviata in data 16/11/2017 (cfr. doc. nn. 21 e 22 allegati all'atto di citazione); 4) il contratto preliminare di compravendita – avente a oggetto il medesimo immobile oggetto del compromesso sottoscritto dalle parti – stipulato tra la **Controparte_1** e **Parte_2** in data 7/12/2013 (cfr. doc. n. 30 allegato alla memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c. di parte attrice).

L'attore ha quindi dimostrato l'esistenza della fonte negoziale del suo diritto e allegato l'inadempimento della convenuta.

A fronte di ciò, la **Controparte_1** ha contestato le deduzioni attoree, depositando: 1) una relazione tecnica di parte tesa a dimostrare il proprio adempimento all'obbligo assunto con il preliminare di realizzare l'aumento di cubatura e ottenere il cambio di destinazione d'uso dell'immobile (doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione); 2) la corrispondenza intercorsa tra le parti nel corso del 2017, dalla quale risulta che il **Parte_1** aveva più volte ribadito il proprio interesse alla stipulazione del rogito non solo dopo la data del 30/06/2016, ma anche successivamente alla presentazione, da parte della promittente venditrice, di tutta la documentazione catastale e urbanistica a tal fine necessaria, avvenuta nel febbraio 2017, e che, nonostante gli inviti a procedere alla stipula, l'attore aveva continuato a chiedere rinvii a causa di difficoltà riscontrate nel conseguimento del mutuo (doc. n. 3 e doc. nn. 5-12 allegati alla comparsa di costituzione).

Ciò posto, occorre anzitutto valutare la condotta della società convenuta, la quale, ad avviso di parte attrice, avrebbe illegittimamente cagionato – attraverso una serie di interventi e variazioni posti in essere successivamente al 30/06/2016 – la trasformazione giuridico-urbanistica dell’immobile, facendo venir meno l’identità del bene oggetto del trasferimento e rendendo in tal modo impossibile la stipula del contratto definitivo.

Sul punto, ritenuto di dover verificare la regolarità urbanistica dell’immobile oggetto del preliminare stipulato tra le parti, nonché l’effettiva presenza di difformità tali da alterare sostanzialmente l’identità dello stesso, è stato ordinato ex art. 210 c.p.c. alla Filiale di Cagliari di *Org_1* di provvedere al deposito della perizia redatta ai fini della richiesta di mutuo avanzata dall’odierno attore, ed è stata altresì disposta una consulenza tecnica d’ufficio.

Invero la consulenza, che in genere ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti (cd. ctu deducibile), può anche costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con ricorso a determinate cognizioni tecniche (ctu percipiente: cfr. ex plurimis Cass. Civ., Sez. II, 30/01/2003, n. 1512; Cass. Civ. 21/7/2003, n. 11332).

Orbene, dalla relazione depositata dal citato *Org_2*, datata 28/05/2012 e risalente al sopralluogo effettuato il 22/05/2017, si evince – contrariamente a quanto dedotto dal *Parte_1* – l’insussistenza, all’epoca, di profili di irregolarità urbanistica o catastale dell’immobile costituente oggetto del preliminare: nel suddetto elaborato si legge, invero, che l’appartamento era stato valutato come “*sostanzialmente regolare*” sotto il profilo della situazione urbanistica ed edilizia, e risulta altresì specificato che “*la planimetria catastale corrisponde allo stato di fatto rilevato*”.

Per quanto concerne invece gli esiti dell’espletata c.t.u., deve rilevarsi come, benché l’ausiliare abbia ritenuto di non poter dare una risposta specifica ai quesiti a causa della scarsa chiarezza della documentazione disponibile, nonché dell’impossibilità di accedere all’immobile oggetto di causa poiché risultava essere stato venduto a terzi, dalla stessa possano ugualmente trarsi elementi idonei a valutare il tipo di modifiche apportate all’immobile dalla società convenuta.

Invero il consulente, dopo aver preso atto che il contratto preliminare stipulato tra le parti aveva a oggetto immobili riconducibili alla categoria catastale C/2 (magazzini, locali deposito, ecc.) e alla categoria catastale C/6 (box., posti auto scoperti ecc.) e che non riportava alcuna descrizione grafica di come era l’unità immobiliare o lo stato dei luoghi al momento della sua sottoscrizione, né di come i luoghi stessi avrebbero dovuto essere mutati, ha evidenziato, con valutazioni adeguatamente motivate, esenti da vizi logici e pienamente condivisibili, che:

- 1) dalla documentazione disponibile e dai relativi elaborati grafici era stato possibile appurare che i locali di cui al piano quinto scala A sarebbero stati inizialmente dei locali tecnici e in seguito sarebbero stati trasformati in un vano disimpegno, locale tecnico, terrazzo coperto e in una unità immobiliare descritta come monolocale composta da un vano e un bagno;
- 2) le successive varianti all'intervento di ampliamento – in particolare la variante prot. 90263 del 27/09/2016 e le successive – non sembrano interessare l'immobile in oggetto;
- 3) in definitiva il bene inizialmente promesso in vendita come locale C2 sarebbe stato oggetto di trasformazioni per renderlo abitativo o in parte abitativo.

Da quanto premesso si evince che la descrizione effettuata dal consulente in ordine alle modifiche apportate dalla *Controparte_1* all'immobile oggetto del preliminare risulta sostanzialmente coincidente con quella riportata nella perizia depositata dalla Filiale di Cagliari di *Org_1*, ove nella prima si parla di *“vano disimpegno, locale tecnico, terrazzo coperto ed in una unità immobiliare descritta come monolocale composta di un vano ed un bagno”* e nella seconda di *“appartamento distribuito su unico livello e composto da: ingresso, soggiorno, angolo cottura, bagno, terrazzo. A completamento della proprietà: cantina, posto auto scoperto”*.

Considerato inoltre che la relazione peritale della Banca, risalente al sopralluogo effettuato in data 22/05/2017, si riferisce alla pratica relativa al mutuo richiesto dallo stesso *Parte_1* e che quest'ultimo portò successivamente avanti la suddetta pratica, deve ritenersi che l'attore fosse pienamente consapevole e condividesse le modifiche che erano state apportate all'immobile.

Inoltre, l'ausiliare, nell'evidenziare che le successive varianti all'ampliamento non riguardavano l'immobile oggetto del presente giudizio, pare confermare quanto dedotto dalla società convenuta, e rilevato nella perizia di parte dalla stessa allegata (doc. n. 2 del fascicolo di parte), secondo cui *“le successive integrazioni e varianti apportate all'originario titolo edilizio, così come riportate nella pag. 4 dell'atto di citazione, altro non sono che modifiche redatte per ridistribuire diversamente la capacità edificatoria eccedente su altre unità immobiliari dello stesso fabbricato: la porzione immobiliare in oggetto, rispetto all'originario progetto del 31/01/2014, non ha pertanto subito alcun mutamento (...)”*.

Da ultimo, la c.t.u. non ha evidenziato la presenza di irregolarità urbanistiche o abusi edilizi; del resto, la regolarità degli interventi posti in essere dalla *Controparte_1* risulta adeguatamente comprovata alla luce della documentazione in atti, comprensiva di tutti i titoli edilizi necessari per l'espletamento delle modifiche apportate (cfr. docc. nn. 2-20 allegati all'atto di citazione), nonché dalla già citata perizia depositata da *Org_1*.

In considerazione di quanto esposto, deve pertanto ritenersi che le difformità esistenti tra l'immobile oggetto del contratto preliminare stipulato tra le parti e quello modificato dalla promittente alienante costituiscano la realizzazione di quanto era stato previsto nel citato contratto.

Sotto tale profilo, pertanto, nessun inadempimento può essere ascritto all'odierna convenuta.

Tanto chiarito, è invece pacifico come quest'ultima abbia provveduto al completamento delle pratiche necessarie per il conseguimento dell'aumento di cubatura e del cambio di destinazione d'uso dell'immobile solo nel mese di febbraio 2017, non rispettando né il termine del 15/05/2016 indicato dal preliminare per l'espletamento di tali incombenzi, né quello del 30/06/2016 fissato per la stipula del contratto definitivo.

Da questo punto di vista, pertanto, è evidente l'inadempimento, *sub specie* di adempimento tardivo, della Controparte_1

Occorre tuttavia ricordare, come già rilevato in premessa, che tanto il recesso quanto la risoluzione del contratto postulano, a monte, la sussistenza di un inadempimento di non scarsa importanza.

Al riguardo, è noto che, al fine di valutare la gravità dell'inadempimento, il giudice *“deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo a uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, a opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità”* (Cass. Civ., Sez. II, 05/03/2019, n. 6364).

Orbene, in ossequio al succitato principio, non si ritiene che il ritardo della promittente venditrice nell'esecuzione degli interventi cui si era impegnata con il preliminare possa essere qualificato alla stregua di un grave inadempimento, tale da legittimare il recesso o la risoluzione del contratto.

Invero, dallo scambio di corrispondenza intercorso tra le parti, prodotto dalla società convenuta e mai contestato dalla controparte, emerge chiaramente come anche successivamente al completamento delle pratiche e alla consegna della documentazione (febbraio 2017), il Parte_1 fosse ancora interessato alla sottoscrizione del contratto definitivo, tanto che la stipula del rogito veniva rinviata non più a causa dell'incompletezza della documentazione fornita dalla CP_1, ma bensì delle difficoltà incontrate dal medesimo nel conseguimento del mutuo.

In tal senso, risultano emblematiche una serie di e-mail inoltrate tra settembre e ottobre del 2017 dall'odierno attore: l'e-mail del 25/09/2017, in cui si legge che *“questa settimana dovrebbe arrivare la*

risposta della **Org_3** in merito alla mia richiesta di mutuo (...) ho sollecitato una risposta venerdì scorso e mi hanno chiesto ancora qualche giorno di pazienza. Il Notaio (...) ha già tutti gli atti necessari per la stipula”; l’e-mail del 04/10/2017, con la quale specificava che “**Org_1** sta indagando e mi chiede visura camerale e catastale di una società di cui la mia famiglia e io facciamo parte (...) Chiedono info sulle garanzie in merito ad un residuo di mutuo. (...) mi impegno per dare buon esito a questo iter quanto prima”; l’e-mail del 16/10/2017, con cui dichiarava che “per ovviare alla pesante burocrazia che appesantisce l’iter della pratica per la mia richiesta di mutuo, ho proposto una variante che riducesse il prestito (...) e avviato una procedura con la consulente di famiglia per accreditare sul mio conto, a titolo di conferma della serietà delle mie intenzioni, la somma di 50.000 euro destinata all’acquisto della casa di Via Bonelli”; l’e-mail del 21/10/2017, con cui richiedeva altresì di “voler intanto accogliere un acconto di 10.000 euro che verserò sul conto della società **CP_1** entro venerdì prossimo” (cfr. documenti allegati al fascicolo di parte convenuta).

Orbene, alla luce di tali comunicazioni risulta evidente come il tardivo adempimento della promittente alienante non avesse inciso in maniera apprezzabile sull’economia complessiva del rapporto, né frustrato l’interesse della controparte all’esecuzione del contratto.

Le suesposte considerazioni inducono altresì a escludere la natura essenziale del termine del 30/06/2016, indicato nel preliminare per la stipula del contratto definitivo.

Secondo costante orientamento della Corte di Cassazione, infatti, il termine per l’adempimento può considerarsi essenziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 c.c., soltanto qualora alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell’oggetto del contratto “risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del contratto con l’inutile decorso del termine medesimo, che non può essere desunta solo dall’uso dell’espressione “entro e non oltre”, riferita al tempo di esecuzione della prestazione, se non emerga, dall’oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti, che queste hanno inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l’utilità prefissatasi” (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 15/07/2016, n. 14426).

Ne consegue che le espressioni utilizzate dalle parti rappresentano soltanto uno degli elementi che il giudice è chiamato a valutare nell’indagine circa l’essentialità o meno del termine.

Nel caso di specie, pertanto, non risulta dirimente che nel contratto preliminare la data del 30/06/2016 fosse definita come “termine essenziale ed improrogabile”, in quanto l’essentialità del termine è chiaramente smentita dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, precedentemente richiamata, dalla quale si evince come la scadenza del termine non avesse comportato il venir meno dell’utilità economica del contratto che le parti si prefiggevano di perseguire.

Peraltro, pur ammettendo che il predetto termine fosse da considerarsi essenziale, lo stesso risulterebbe comunque rinunciato dal *Parte_1* in virtù delle reiterate dichiarazioni di interesse all'esecuzione del contratto, indicative di una volontà incompatibile con l'intenzione di avvalersi della clausola che prevedeva il termine: *“La previsione di un termine essenziale per l'adempimento di un contratto, essendo posto nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata la rinuncia ad avvalersene. La rinuncia - anche tacita - alla osservanza del termine essenziale, inoltre, bene può intervenire dopo la scadenza del termine stesso, tenuto conto che con essa la parte rinuncia anche ad avvalersi di tale termine ai fini di ottenere la dichiarazione di risoluzione del contratto”* (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 05/07/2013, n. 16880).

Ne discende che, anche sotto tale aspetto, le deduzioni svolte dall'odierno attore non meritano di essere condivise.

Occorre a questo punto soffermarsi su quanto rilevato dalla *Controparte_1* secondo la quale, a partire dal febbraio del 2017, sussistevano tutte le condizioni per la stipula del rogito, cui il *Parte_1* veniva più volte invitato a procedere e diffidato ad adempiere in data 16/11/2017.

Al riguardo, con specifico riferimento alla citata diffida ad adempiere, giova richiamare quanto disposto dall'art. 1454 c.c., ai sensi del quale *“Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto”*.

La diffida ad adempiere costituisce, dunque, uno strumento a disposizione della parte non inadempiente per provocare la risoluzione di diritto del contratto, di modo che, decorso il termine nella stessa indicato, il contratto è risolto *ope legis* senza che sia necessaria una pronuncia del giudice, la quale assumerebbe eventualmente una natura meramente dichiarativa.

Per produrre l'effetto sopra descritto, tuttavia, la dichiarazione di diffida deve contenere determinati elementi essenziali, individuabili nell'intimazione all'adempimento, nella fissazione del termine concesso al debitore per adempiere e nell'espresso ammonimento che il contratto s'intenderà risolto laddove entro il predetto termine il contraente non adempia alla propria prestazione.

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, *“In tema di diffida ad adempiere, l'unico onere che, ai sensi dell'art. 1454 c.c., grava sulla parte intimante è quello di fissare per iscritto un termine entro cui l'altra dovrà adempiere alla propria prestazione, con l'avvertimento espresso che nell'eventualità in cui l'adempimento non avvenga nel termine previsto seguirà la risoluzione ope legis del contratto, poiché la ratio perseguita dal legislatore è quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all'esecuzione del negozio, mediante un formale avvertimento alla parte diffidata*

che l'intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo nell'adempimento" (cfr. Cass. Civ, sez. III, 10/09/2019, n. 22542).

Ne deriva che la diffida ad adempiere, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali, *"esige la manifestazione univoca della volontà dell'intimante di ritenere risolto il contratto in caso di mancato adempimento della controparte entro un certo termine"* (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 21/02/2006, n. 3742).

Ciò posto, nel caso di specie la diffida comunicata dalla **Controparte_1** all'attore, in data 16/11/2017, non risulta conforme ai requisiti sopra indicati.

Invero, nella citata diffida si legge: *"Con riferimento al compromesso descritto in oggetto la diffidiamo ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c., alle obbligazioni in esso contenute e pertanto a fissare la data di stipula del rogito entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della presente. Rimaniamo in attesa, dunque, di conoscere il nome del notaio che dovrà stipulare l'atto definitivo di compravendita"* (cfr. doc. n. 22 allegato all'atto di citazione).

Orbene, così formulata la diffida, appare corretta nella parte in cui impone all'attore di fissare la data di sottoscrizione del definitivo e di comunicare il nome del notaio, atteso che secondo l'art. 4 del preliminare di compravendita (doc. n. 1 allegato all'atto di citazione) il rogito avrebbe dovuto essere stipulato dal notaio di fiducia del promissario acquirente, cui competeva l'obbligo di avvisare la parte promittente venditrice.

Essa difetta, tuttavia, dell'espresso avvertimento che, decorso il termine indicato per l'adempimento, il contratto si sarebbe considerato risolto di diritto, non potendosi reputare a tal fine sufficiente il mero richiamo all'art. 1454 c.c..

La mancanza del suddetto avviso, invero, frustra lo scopo proprio dell'istituto in questione, consistente – come ricordato – nel fissare con chiarezza la posizione delle parti circa l'esecuzione del contratto, sicché la diffida che ne sia priva viene ad assumere il valore di una mera sollecitazione all'adempimento, in quanto tale non sussumibile nel paradigma di cui al citato art. 1454 c.c. e non suscettibile di provocarne gli effetti.

Ne discende, in definitiva, l'inidoneità della diffida ad adempiere comunicata dalla **Controparte_1** in data 16/11/2017, a produrre l'effetto risolutivo del contratto preliminare stipulato tra le parti.

Parimenti alcun effetto risolutivo può ricondursi alla lettera di contestazione dell'inadempimento inviata dal **Parte_1** alla convenuta il 28/11/2017 e da quest'ultima ricevuta in data 30/11/2017 (cfr. doc. n. 21 allegato all'atto di citazione).

Nella citata missiva, invero, veniva intimato alla **Controparte_1** di procedere al pagamento *"del doppio della caparra e – quindi – della somma di euro 30.000, oltre al rimborso della somma di euro*

5.000 corrisposta per spese di agenzia, nonché oltre al risarcimento di ogni ulteriore danno (..)", specificando che, in mancanza, si sarebbero adite le vie legali.

Orbene, al riguardo occorre considerare che, come noto, il recesso dal contratto con ritenzione della caparra (o pretesa al pagamento del doppio di quella corrisposta) e la risoluzione giudiziale del contratto con risarcimento dei conseguenti danni costituiscono due rimedi fra loro alternativi e non cumulabili. La circostanza, dunque, che con la lettera del 28/11/2017 fosse stato richiesto il pagamento del doppio della caparra cumulativamente al rimborso delle spese di agenzia e al risarcimento di ogni ulteriore danno, non consente di evincere in maniera univoca quale fosse l'intenzione dell'odierno attore, se di esercitare il diritto di recesso ovvero di agire per conseguire la risoluzione giudiziale del contratto.

Alla luce di quanto esposto, e in mancanza di accordo per mutuo dissenso o di dichiarazione di recesso in forma scritta, deve ritenersi che il contratto preliminare del 5/02/2016 fosse all'epoca ancora vigente tra le parti.

Ne consegue che risulta essere certamente sussistente l'ultima fattispecie inadempitiva ascritta dal *Parte_1* alla promittente venditrice.

Emerge dagli atti allegati dall'attore, invero, che la *Controparte_1* nella vigenza del contratto preliminare per cui è causa, avesse promesso in vendita il medesimo immobile a terzi, con contratto trascritto in data 13/12/2017 (cfr. doc. nn. 30 e 31 allegati alla memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c. di parte attrice).

Si evince inoltre dalla espletata CTU che l'immobile promesso in vendita è stato poi effettivamente alienato a terzi.

Appare pertanto evidente la gravità di tale inadempimento che ha reso definitivamente irrealizzabile il programma negoziale previsto dalle parti con il citato contratto preliminare.

Né rileva che la connotazione di gravità di tale inadempimento sia stata raggiunta solo nel corso del procedimento, con l'effettiva alienazione a terzi del bene che, al tempo dell'atto introduttivo, era stata solo promessa.

La Suprema Corte ha chiarito, infatti, che la gravità dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., è condizione dell'azione di risoluzione e, in quanto tale, deve esistere al momento della decisione e non necessariamente al momento della proposizione della domanda (v. Cass. Civ., Sez. II, 11/06/2013, n. 14649).

Da quanto premesso discende la legittimità del recesso esercitato dall'attore.

Invero, pur non potendosi riconnettere valenza di dichiarazione di recesso alla sopra citata missiva del 28/11/2017, tale dichiarazione risulta nondimeno chiaramente effettuata con l'atto introduttivo del

presente giudizio: la comunicazione del recesso, infatti, pur dovendo essere formulata per iscritto ove relativa allo scioglimento di un contratto formale, può senz'altro essere effettuata attraverso l'atto di citazione.

In conformità al disposto di cui all'art. 1385 c.c., pertanto, la *Controparte_1* deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 30.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria da quest'ultimo corrisposta all'atto della sottoscrizione del preliminare, oltre interessi legali dalla domanda (coincidente con la notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 10/01/2018) al saldo.

Non spetta invece la rivalutazione in difetto di prova del maggior danno non coperto dagli interessi.

La Suprema Corte ha chiarito, infatti, che la parte non inadempiente che, avendo versato la caparra, recede dal contratto per l'inadempimento dell'altra e chiede il pagamento del doppio, ai sensi dell'art. 1385, secondo comma, cod. civ., accetta tale somma a titolo di integrale risarcimento del danno conseguente all'inadempimento e non può, dunque, pretendere ulteriori e maggiori danni, neppure sotto forma di rivalutazione monetaria della caparra stessa, atteso che il ritardo nell'adempimento del relativo credito, di natura pecuniaria e assoggettato al principio nominalistico sino alla data del pagamento, può essere causa di un'obbligazione risarcitoria del debitore solo in presenza dei presupposti indicati dall'art. 1224 cod. civ. (si veda tra molte Cass. Civ. Sez. II 20/12/2013 n. 28573).

In virtù dell'accoglimento della domanda di recesso formulata in via principale, restano assorbite le ulteriori domande proposte dall'attore in via subordinata.

Non sussistono invece i presupposti per la condanna della *Controparte_1* al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., chiesta dal *Parte_1* con la prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., considerato che la parte istante non ha provveduto né a indicare le conseguenze dannose che avrebbe subito né ad allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato.

Dall'accoglimento della domanda attorea deriva, infine, il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla convenuta.

Le spese di lite, comprensive delle spese della espletata CTU, seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto, quanto al valore della controversia, del contenuto effettivo della decisione (cd. criterio del "decisum": cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 11/09/2007, n. 19014; nello stesso senso da ultimo Cass. Civ., Sez. III, 20/10/2016, n. 21256) e applicando la tariffa minima per la fase istruttoria/ trattazione attesa l'assenza di attività istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. In accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara legittimo il recesso esercitato da *Parte_1* dal contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti in data 5/02/2016, per il grave inadempimento della *Controparte_1*
2. Per l'effetto, condanna la *Controparte_1* in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 30.000,00, oltre interessi dal 10/01/2018 al saldo;
3. Condanna altresì la convenuta alla refusione, in favore dell'attore, delle spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 6.738,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4. Pone definitivamente a carico della convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, con i conseguenti effetti restitutori.

Roma, 05/07/2021

Il Giudice
dott. Raffaele Miele

(Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del *CP_2* dott.ssa Giuseppina Vendemiale)